

EXAME PRÉVIO DE EDITAL
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 05-06-2024 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processo: TC-009975.989.24-5.

Representante: THESIS - Engenharia e Construções Eireli.

Representada: Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos.

Assunto: Exame prévio do edital retificado da Tomada de Preços nº 37/2023, do tipo menor preço global, objetivando a *“contratação de empresa especializada para execução da elaboração do Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbana”*.

Responsável: Priscila Conceição Gambale Vieira Matos (Prefeita).

Subscritores do edital: Antonio Carlos do Santos Ferreira (Secretário Municipal de Obras), Thiago Trevizolli de Souza (Presidente da Comissão Municipal de Licitações).

Advogado cadastrado no e-TCESP: Alan Santana da Silva (OAB/SP nº 441.754).

=====

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS. ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANA. MENOR PREÇO. INDEVIDA ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO. ATIVIDADES REVESTIDAS DE CARÁTER EMINENTEMENTE INTELECTUAL. ANULAÇÃO.

1 - RELATÓRIO

1.1 Trata-se de **exame prévio do edital** retificado da Tomada de Preços nº 37/2023, do tipo menor preço global, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS**, que tem por objetivo contratar

“empresa especializada para execução da elaboração do Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbana”.

1.2 Insurgiu-se a **REPRESENTANTE** contra os seguintes aspectos do instrumento convocatório:

a) critérios da avaliação da capacidade-técnica operacional e profissional¹, que se limita a mencionar os anos de formação dos respectivos profissionais indicados como parcelas de maior relevância, sem justificativas;

¹ 5.3.2.1. A comprovação de qualificação operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, c/c Súmula nº 24 TCESP, deverá ser apresentada mediante apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, cujas parcelas de maior relevância são:

FORMAÇÃO	EXPERIÊNCIA NA ÁREA	FUNÇÃO	DEDICAÇÃO (Horas)
Engenharia Civil/Ambiental/Saneamento; Registro no Conselho Regional de Classe	10 anos ou mais na elaboração de Planos de Drenagem	Consultoria na elaboração do Plano de Drenagem	648
Engenharia Civil/Ambiental/Saneamento; Registro no Conselho Regional de Classe	10 anos de experiência na área de formação	Coordenador Geral do Projeto	552
Engenharia Civil/Ambiental/Saneamento; Registro no Conselho Regional de Classe	5 anos de experiência na área de formação	Analista técnico – engenharia – responsável pelo planejamento e execução das atividades	1044
Engenharia Civil/Ambiental/Saneamento; Registro no Conselho Regional de Classe	5 anos de experiência na área de formação	Analista técnico – engenharia responsável pela execução das atividades	1045
Técnico em Agrimensura	5 anos de experiência na área de formação	Técnico agrimensor para levantamentos em campo	4016
Serviço Social; Registro no Conselho Regional de Classe	5 anos de experiência na área de formação	Assistente social Pleno – atividades sociais e educação ambiental	80
Geógrafo com especialização em Geoprocessamento	5 anos de experiência na área de formação	Atividades de adequação, tratamento e armazenamento dos dados em sistema SIG	1248
Analista de Sistemas	5 anos de experiência na área de formação	Atividades de instalação e suporte da infraestrutura de banco de dados e de documentos	416
Administração de empresas	3 anos de experiência na área de formação	Analista de planejamento para auxiliar no planejamento e na execução do projeto	384

5.3.2.2. A comprovação quanto a capacidade técnico profissional da licitante, nos termos do inciso I, do § 1º do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, c/c Súmula nº 23 TCESP, far-se-á mediante a comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional(is) de nível superior devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU, detentor(es) de Certidão de Acervo Técnico (CAT), por execução dos serviços de maior relevância a seguir:

FORMAÇÃO	EXPERIÊNCIA NA ÁREA	FUNÇÃO
Engenharia Civil/Ambiental/Saneamento; Registro no Conselho Regional de Classe	10 anos ou mais na elaboração de Planos de Drenagem	Consultoria na elaboração do Plano de Drenagem
Engenharia Civil/Ambiental/Saneamento; Registro no Conselho Regional de Classe	10 anos de experiência na área de formação	Coordenador Geral do Projeto

- b) estranha exigência de “Administração de Empresas” dentre as áreas de expertise requeridas;
- c) indevida adoção do critério de julgamento pelo “menor preço global”, já que a requisição de equipe multiprofissional em diversas áreas da engenharia, aliada ao complexo detalhamento dos serviços contantes no Termo de Referência, indicam que as atividades são de caráter intelectual, demandando o uso do tipo “técnica e preço”;
- d) incongruências acerca da garantia contratual², ora apontada como 3% do valor do contrato, ora como 5%;
- e) adoção da Lei nº 8.666/93 na fase interna, mas com previsão de cabimento das regras da atual norma licitatória para a execução do ajuste³;
- f) menção a custos relacionados a licenças ambientais ou respectivos alvarás de qualquer natureza, sem a correspondente previsão na planilha orçamentária;⁴

<i>Engenharia Civil/Ambiental/Saneamento; Registro no Conselho Regional de Classe</i>	<i>5 anos de experiência na área de formação</i>	<i>Analista técnico – engenharia – responsável pelo planejamento e execução das atividades</i>
<i>Engenharia Civil/Ambiental/Saneamento; Registro no Conselho Regional de Classe</i>	<i>5 anos de experiência na área de formação</i>	<i>Analista técnico – engenharia responsável pela execução das atividades</i>
<i>Técnico em Agrimensura</i>	<i>5 anos de experiência na área de formação</i>	<i>Técnico agrimensor para levantamentos em campo</i>
<i>Serviço Social; Registro no Conselho Regional de Classe</i>	<i>5 anos de experiência na área de formação</i>	<i>Assistente social Pleno – atividades sociais e educação ambiental</i>
<i>Geógrafo com especialização em Geoprocessamento</i>	<i>5 anos de experiência na área de formação</i>	<i>Atividades de adequação, tratamento e armazenamento dos dados em sistema SIG</i>
<i>Analista de Sistemas</i>	<i>5 anos de experiência na área de formação</i>	<i>Atividades de instalação e suporte da infraestrutura de banco de dados e de documentos</i>
<i>Administração de empresas</i>	<i>3 anos de experiência na área de formação</i>	<i>Analista de planejamento para auxiliar no planejamento e na execução do projeto</i>

² 10.1.0. A empresa vencedora da presente licitação deverá no prazo de até 05 (cinco) dias após a assinatura do Contrato, recolher a garantia contratual no valor equivalente a 3% (três por cento) do valor do contrato, nos termos do artigo 56, da Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94 (item 11.1.1.). (...)

11.1.1. Recolher caução contratual no valor de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do artigo 56, da Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94 (item 10.1.0), no prazo de até 05 (cinco) dias após assinatura do Contrato.

³ 11.5.0. A contratação da empresa vencedora obedecerá no que couber, as disposições contidas nas Leis Federais n.º 8.880/94, 9.069/95 e 10.192/01, ou outra que a revalide ou substitua, e que esteja em vigor na data da assinatura do Contrato;

g) imposição de protocolo físico para as impugnações e recursos administrativos⁵; e

h) redação do item 24.3.0⁶, que pode conduzir ao entendimento de que a Administração não estará vinculada aos termos do seu edital.

1.3 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi decretada liminarmente por este E. Plenário.

1.4 Regularmente notificada, a **Representada** reconheceu a existência de erro material entre as cláusulas que tratam da garantia do contrato, esclarecendo que o percentual correto seria de 5% (cinco por cento).

Aduziu que, inobstante tenha o item 24.1.0 do edital feito menção a protocolo físico das impugnações e recursos administrativos, o item 22 teria possibilitado o envio de impugnações por meio de correio eletrônico.

No que tange à adoção da norma de licitações revogada na fase de contratação, afirmou que o item 11.5.0 refere-se apenas *“às questões ligadas ao Plano Real e o Sistema Monetário Nacional, não se confundido com a Lei Federal 8.666/93 que rege o edital licitatório em comento”*.

A Secretaria Municipal de Obras detalhou os critérios a serem adotados no julgamento das propostas técnicas.

De outro modo, assentiu com a exclusão da prova de *expertise* em “administração de empresas”, bem como do item 20.18.0, que menciona custos relacionados a licenças ambientais e alvarás.

⁴ 20.18.0 Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no Termo de Referência (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: “habite-se”, licenças ambientais, alvarás, etc.);

⁵ 24.1.0 Não serão aceitas impugnações, recursos, propostas ou quaisquer outros documentos enviados por via postal, por email ou por fac-símile, ressalvado o item 4.8.0.

24.1.1 Qualquer pedido de impugnação ou interposição de recursos deverá ser protocolado no Setor de Protocolo desta Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, no horário compreendido entre 09:00 e 16:00 horas, de Segunda à Sexta-feira, observando as disposições dos artigos 41 e 110 da Lei nº 8666/93.

⁶ 24.1.1 Qualquer pedido de impugnação ou interposição de recursos deverá ser protocolado no Setor de Protocolo desta Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, no horário compreendido entre 09:00 e 16:00 horas, de Segunda à Sexta-feira, observando as disposições dos artigos 41 e 110 da Lei nº 8666/93.

Por fim, concordou em alterar o critério de julgamento para técnica e preço.

1.5 A **Unidade de Engenharia da Assessoria Técnico-Jurídica**, nos aspectos atinentes à sua área de atuação, pronunciou-se pela procedência da representação.

Constatou que, de fato, as parcelas de maior relevância eleitas não coincidem com os serviços a serem executados, mas se referem à composição da equipe técnica mínima para o projeto. Assim, anotou o descumprimento do artigo 30, §2º, da Lei nº 8.666/93 e da jurisprudência desta Casa.

Além disso, avaliou que a exigência de profissional de Administração de Empresas não se relaciona aos serviços descritos no Edital.

Entendeu que a escolha do critério de julgamento se insere na discricionariedade da Administração, desde que adequadamente justificada sua opção e observadas as normas de regência. No caso, entendeu proceder a queixa, pela falta de tais elementos.

Ponderou, ainda, que *“os alvarás e licenças que fazem parte desses serviços descritos no item 3 do Edital, inclusive aqueles relativos aos locais que se abrigarão as equipes, devem constar do Edital e, por sua vez, devem ter seus custos explicitados na planilha orçamentária”*.

1.6 Sua congênere **Jurídica** afastou a crítica à colidência da legislação citada no edital, destacando que *“as Leis Federais nº 8.880/94, 9.069/95 e 10.192/01 ali mencionadas se referem às questões ligadas ao Plano Real e o Sistema Monetário Nacional, em nada indicando a aplicação da NLLC”*.

Igualmente, ponderou ser improcedente a crítica direcionada ao subitem 24.3.0, posto que *“eventual decisão sobre a recusa de proposta deve ser motivada e sobre tal decisão caberá recurso administrativo nos termos previstos no item 23 do Edital”*.

Também não subsiste, a seu ver, a crítica à afronta à separação de poderes, pois *“a solução de casos omissos por parte da Sra. Prefeita Municipal será proposta, após a oitiva dos órgãos técnicos e especializados, nos termos da norma de regência, no caso, Lei nº 8.666/93, não importando a regra no exercício de poder legislativo”*

Por outro lado, subsiste a queixa à exigência de protocolo físico de impugnações e recursos administrativos, *“ensejando a correção do edital para que passe a admitir também a interposição de recursos por meio eletrônico e sanar a incongruência entre os itens 22 e 24.1.0 demanda correção”*.

1.7 A **Chefia da ATJ** dissentiu de sua assessoria em relação ao critério de julgamento, destacando que *“a gama de variações possíveis no resultado produzido, em especial nas soluções apresentadas, é incongruente com um critério de seleção que pressupõe igualdade entre as empresas em termos de qualidade de recursos humanos e operacionais”*.

Além disso, quanto ao subitem 20.18.0, explicou não ter localizado no “Edital, Termo de Referência e demais Anexos qualquer alusão a instalações que demandem *“ligações definitivas de água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.”* ou a *“obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: ‘habite-se’, licenças ambientais, alvarás, etc.)”*. Desta forma, avaliou que a cláusula foi utilizada equivocadamente pela Administração, propondo que se excluam do Edital todos os itens que não condizem com o escopo do certame.

Por fim, em relação ao subitem 24.3.0, consignou que *“os critérios de classificação e desclassificação de propostas devem ser objetivos e constar expressamente do Edital, não havendo respaldo normativo a cláusula que prevê, de forma isolada, a possibilidade de aceitação ou recusa de qualquer proposta pela Administração, sem referência aos demais termos do Ato Convocatório”*.

Verificou, ainda, que o subitem 24.7.0 carece da mesma subjetividade, destacando que o § 5º do artigo 43 da Lei Federal n. 8.666/93

estabelece que *“ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes (incisos I e II) e abertas as propostas (inciso III), não cabe desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento”*.

1.8 O parecer do **Ministério Público de Contas** não destoou daqueles de seus antecessores, alinhando-se às ressalvas tecidas pela Chefia da ATJ.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos pretende contratar *“empresa especializada para execução da elaboração do Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbana”*.

No entanto, a instrução da matéria revela a impossibilidade de prosseguimento do certame nos moldes pretendidos pela Administração.

2.2 De plano, entendo que o objeto licitado não comporta o julgamento pelo menor preço.

Como bem destacou a Chefia da ATJ, *“a gama de variações possíveis no resultado produzido, em especial nas soluções apresentadas, é incongruente com um critério de seleção que pressupõe igualdade entre as empresas em termos de qualidade de recursos humanos e operacionais”*.

A prevalência da técnica, aliás, fica evidente no próprio edital, que impõe, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional e profissional das licitantes, extenso rol de profissionais com larga experiência na sua área de formação. Essa, aliás, uma das queixas apresentadas na inicial.

Tais exigências, próprias dos tipos de licitação “melhor técnica” ou “técnica e preço”, não se coadunam com o menor preço, como reconhecido, inclusive, pela Representada.

Assim, não há como afastar, no caso, a aplicação do artigo 46 da Lei federal nº 8.666/93, impondo-se a reformulação do edital para que se adéque o critério de julgamento à lei de regência.

2.3 Não obstante, oportuno discorrer sobre as demais impugnações, de forma a evitar sobrevida de irregularidades em eventual novo edital.

De plano, necessário que sejam reavaliadas as cláusulas de habilitação técnica, conformando-as ao critério de julgamento a ser adotado.

Para tanto, necessário, também, que sejam discriminados adequadamente os parâmetros de ponderação das notas.

2.4 Outrossim, incontroversa a inadequação da exigência de profissional da área de Administração de Empresas, como reconhecido pela própria Representada.

2.5 Igualmente, a menção a custos relacionados a licenças ambientais ou respectivos alvarás (item 20.18.0) se mostra alheia ao objeto licitado, devendo ser excluída do edital.

2.6 No que tange ao item 24.3.0, assim como a Chefia da ATJ, entendo que *“os critérios de classificação e desclassificação de propostas devem ser objetivos e constar expressamente do Edital, não havendo respaldo normativo a cláusula que prevê, de forma isolada, a possibilidade de aceitação ou recusa de qualquer proposta pela Administração, sem referência aos demais termos do Ato Convocatório”*.

De igual modo, constatou aquela Chefia que o subitem 24.7.0⁷ carece da mesma subjetividade, devendo ser adequado ao § 5º do artigo 43 da Lei nº 8.666/93, ressaltando que, *“ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes (incisos I e II) e abertas as propostas (inciso III), não cabe desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento”*.

2.7 Inconteste, ainda, a incongruência havida entre as cláusulas que tratam da garantia do contrato, as quais devem ser uniformizadas.

2.8 Pertinente que se possibilite a apresentação de pedidos de impugnações e recursos por meios eletrônicos, a fim de viabilizar o exercício desse direito para licitantes que não possam comparecer diretamente à sede do órgão contratante.

2.9 Inobstante tais aspectos desfavoráveis, inexiste no subitem 11.5.0 colidência entre normas, pois, como sublinhou a ATJ, a cláusula se refere apenas a *“questões ligadas ao Plano Real e o Sistema Monetário Nacional, em nada indicando a aplicação da NLLC”*.

2.10 Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero que o edital apresenta **vício insanável**, relacionado à adoção do julgamento pelo menor preço para serviços complexos e de natureza predominantemente intelectual, o que impõe sua **nulidade**.

Ainda assim, considero **parcialmente procedentes** as impugnações, determinando que a Administração, em eventual novo certame, adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial para:

⁷ 24.7.0. A Administração Municipal poderá desqualificar quaisquer dos concorrentes, inclusive a vencedora do certame, se for notificado fato que lhe desabone ou desacredite a idoneidade técnica, financeira ou administrativa sem que lhe assista, neste caso, direito de indenização ou ressarcimento;

- a) reavaliar as cláusulas de habilitação técnica, conformando-as ao critério de julgamento a ser adotado;
- b) discriminar adequadamente os parâmetros de ponderação das notas;
- c) deixar de impor a presença de profissional da área de Administração de Empresas;
- d) excluir menção a custos relacionados a licenças ambientais ou respectivos alvarás (item 20.18.0);
- e) readequar a redação dos subitens 24.3.0 e 24.7.0;
- f) corrigir a incongruência entre as cláusulas que tratam da garantia do contrato; e
- g) possibilitar a apresentação de pedidos de impugnações e recursos por meios eletrônicos.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve, por fim, atentar para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 05 de junho de 2024.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
CONSELHEIRO